

--- סוף עמוד 340 ---

ערעור אזרחי מס' 360/83

1. סטרוסקי בע"מ

2. יהושע סטרוסקי

נגד

1. גלידת ויטמן בע"מ

2. מחלבת נהריה שטראוס בע"מ

בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

[8.9.85]

לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים ש' נתניהו, א' גולדברג

חוק זכות יוצרים, 1911, חא"י כרך ג', (ע) 2633, (א) 2475, סעיפים (1)5, (א)5, 22, (1)22, (2)22, (1)35 - דבר המלך על חוק הקופירייט, 1911 (הטלתו על ארץ ישראל), 1924, (ע) 2661, (א) 2499 פקודת הפטנטים והמדגמים, חא"י כרך ב, (ע) 1053, (א) 1076 - חוק העונשין, תשל"ז-1977, ס"ח 226 - תקנות המדגמים, חא"י כרך ג, (ע) 1957, (א) 1910, תקנה 72.

מיני-רציו:

* זכויות יוצרים – הפרה – על-ידי העתקה

* זכויות יוצרים – יצירה – יצירה אמנותית

* פטנטים – מדגמים – הגדרתו

* פרשנות – מונחים – יצירה אמנותית

* פרשנות – מונחים – יצירה ספרותית

המשיבות, יצרניות גלידה, הזמינו אצל המערערים שהם גרפיקאים, שלטים לשימוש מסחרי בעסקן. המשיבות ביקשו שהשלטים יכללו את שם הפירמה ופרח, שהמשיבות עשו בו שימוש קודם לכן; כמו כן הוסכם, שבשטים יהיו גם פסים, כפי שהנהיגו המערערים בפרסומת שעיצבו עבור לקוחות אחרים. המערערים עיצבו את השלטים תוך שימוש ביסודות אלה. את שם הפירמה עיצבו באותיות בעלות אותו עיצוב שבו השתמשו המשיבות כבר קודם לכן על אריזות הגלידה שייצרו. אריזות אלה לא הוצגו למערערים בעת הזמנת השלטים, אולם הגלידה באריזות הללו נמכרה באופן חופשי בשוק. בין הצדדים נעשה הסכם בעל-פה, בו נקבע מחיר עבור כל שלט שיתקינו המערערים על-פי הדגם שעוצב על-ידיהם ושקיבל הסכמת המשיבות, תוך התייעצות. על-פי הסכם זה יצרו המערערים שלטים עבור המשיבות, והמשיבות שילמו עבורם מחיר שהשתנה לפי גודל השלטים, צורתו ומועד אספקתו - אך הכול על-פי אותו הדגם. לאחר שינויי בעלות במשיבה 1, הפסיקו המשיבות את קשריהן עם המערערים והזמינו שלטים לפי אותו דגם, תוך שינויים מסוימים, מחברה אחרת. המערערים עתרו לבית המשפט המחוזי בעילה של הפרת זכות יוצרים. בית המשפט המחוזי

קבע, כי השלט שעוצב על-ידי המערערים הינו "יצירה אמנותית מקורית" הראויה להגנה על-פי [חוק זכות יוצרים](#), 1911, אולם הוא דחה את התביעה, מהטעם שהשלט מהווה "פיתוח" במובן סעיף 5(א) לחוק הנ"ל, ולפיכך המשיבות, שהשלט הוכן על-פי הזמנתן בתמורה, הן בעלות זכות היוצרים עליו, בהעדר הסכם תמורה אחרת. מכאן הערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון פסק:

א. (1) הגנת זכות יוצרים אינה ניתנת לרעיון מופשט אלא לביטוי הממשי של רעיון. ביטוי זה צריך שיהיה מקורי, לא במשמעות של ביטוי של מחשבה או המצאה חדשנית או בת-חידוש כלשהו, אלא בכך שהיצירה לא תהיה מועתקת מיצירה אחרת, ומקורה יהיה ביוצרה, במחברה.

(2) כדי שהיצירה תהיה מוגנת, היא צריכה להיות פרי מאמץ, כישרון והשקעה, ולו גם במידה צנועה ביותר, ובלבד שיש בהם כדי להקנות לה אופי שונה משל החומרים שמהם עוצבה. כל שינוי מעבודה קודמת שניתן להבחין בו, די בו, אם השינוי הוא פרי מאמצו העצמאי של המחבר.

--- סוף עמוד 341 ---

(3) פשטות היצירה בלבד לא תמנע הגנת זכות יוצרים, אלא אם כן היא קיצונית, כגון סתם קו ישר או עגול.

(4) כדי לבחון אם היצירה ראויה להגנה יש לראותה בכללותה, כשלמות אחת.

(5) המאמץ והכישרון, הכרוכים בליקוט, בסידור ובעריכה של נושא קיים, יכולים להספיק, כדי שתינתן הגנה ליצירה.

ב. (1) המושגים "יצירה אמנותית" ו"יצירה ספרותית" אינם מבטאים במובן [חוק זכות יוצרים](#) את התפיסה המקובלת של יצירה בעלת רמה וערך. כדי שייצירה תיחשב כיצירה אמנותית או ספרותית, די בכך שהיא פונה לטעמו של מיגזר מהציבור.

(2) די ליצירה "אמנותית" שתהא תולדה ממידת מה של כישרון ועבודה של האמן.

(3) אמנות שימושית גם היא בכלל אמנות, ויצירה שנועדה לתצרוכת מסחרית או לפרסומת גם היא זכאית להגנה.

(4) במקרה דנן, השלט הוא יצירה מקורית הראויה להגנה. אמנם במרכיביו לא היו חידוש ומקוריות, אולם די בכך שהמערערים עמלו והשתמשו בכישוריהם המקצועיים וחיברו את כל הרכיבים ליצירה חדשה, משלהם, שמקורה בהם ושאינה העתק של יצירה אחרת.

ג. (1) טקסט שבפרסומת יכול להיחשב כיצירה ספרותית, אם הוא יצירה הראויה להגנה, בעוד שהחלק הציורי או הגרפי של אותה פרסומת יכול להיחשב כיצירה אמנותית. כך המצב לגבי הדפסות, תוויות, מפות וסיפורים מצוירים המכילים תמונה וטקסט.

(2) כדי שייצירה תהיה ראויה להגנה כ"יצירה ספרותית", צריכה היא לתת ביטוי בכתב לרעיון כלשהו, דל ככל שיהיה, וצריכה היא למקוריות ולמידת מה של מאמץ וכישרון.

(3) במקרה דנן, בטקסט שבשלט האותיות אינן יצירתם של המערערים, השם הוא נתון קיים ומוכר, ואין לו מקוריות, לא יצירותיות ולא ביטוי לרעיון כלשהו בטקסט כחומר כתוב. הוא מהווה חלק מהעיצוב הגרפי, אך אין כל תפקיד עצמאי כחומר כתוב.

ד. (1) הכללת מפות, תרשימים ותכניות נעדרי כל טקסט כתוב בגדר הגדרת "יצירה ספרותית" בסעיף 35(1) [לחוק זכות יוצרים](#) היא אנומאליה, שבגינה אין מנוס גם מן הקביעה, שתכנית אדריכלית או סדרת מעגלים חשמליים מודפסים הם "יצירה ספרותית".

(2) אין להרחיב את האנומאליה האמורה מעבר למתחייב מן ההגדרה, ולפיכך יש לראות את השלט במקרה דנן כ"יצירה אמנותית" ולא כ"יצירה ספרותית".

ה. (1) התרגום העברי של הגדרת המושג "פיתוח" בסעיף 35(1) [לחוק זכות יוצרים](#) אינו משביע רצון. יש לקרוא שם במקום "כתובת קעקע" - תחריטי מתכת, ובמקום "חיקוקים" - הדפסים.

(2) גם התרגום העברי של סעיף 5(א) לחוק הנ"ל אינו משביע רצון. כשמדובר בדיבור "העתקה מקורית אחרת", הכוונה היא לכל מקור אחר, שממנו או באמצעותו מופקים העתקים, ואילו כשמדובר ב"קלישאה", הכוונה היא לגלופה, דהיינו מדובר בהעתקה, שיכפול או שיעתוק,

הנעשים בהליך המאפשר הפקה המונית מתוך תבנית או לוח או מכשיר אחר מסוג כלשהו שהוכן לשם כך.
(3) במקרה דנן, השלטים, שהוזמנו אצל המערערים על-פי הדגם שעיצבו, לא הועתקו, לא שוכפלו ולא שועתקו בתהליך כלשהו מעין זה, אלא כל אחד מהם יוצר מחדש, באופן עצמאי ונפרד בגדלים ובמידות שונות, אם כי על סמך העיצוב ועל-פי הדגם של השלט הראשון ששימש אב-טיפוס.

ו. (1) המכנה המשותף למושגים השונים, המוזכרים בהגדרת "פיתוח" בסעיף 35(1) [לחק. זכות יוצרים](#), הוא, שהמדובר ביצירות המתקבלות כתוצאה מתהליך מכאני של שימוש בגלופה.

(2) יש להגביל את פירושם של "פיתוחים" בסעיף 35(1) [לחק. זכות יוצרים](#) לתהליכי ייצור, המאפשרים שיעתוק המוני תהליכים מכאניים, כימיים או אחרים, ותהא הטכניקה לכך אשר תהיה. אין לדקדק בדרישה שהתהליך ייעשה בדרך חריטה או חיתוך דווקא. די בטכניקה של תבליט, של תשיל וכל אמצעים שונים אחרים, ככל שחידושי הטכניקה המודרנית המתקדמת מאפשרים.

(3) אין כל טעם והיגיון בהבחנה, לפיה אותה יצירה תוכל להיות "פיתוח" ותוכל שלא להיות "פיתוח", הכול בהתאם לכוונה הסובייקטיבית של יוצרה.

ז. (1) עניינו של מזמין בתמורה של גלופה, המיועדת, מעצם טבעה, להפקה המונית של העתקים, הוא בהעתקים. הגלופה עצמה נשארת, בדרך כלל, בידי היוצר, אך אין להשאיר בידי גס את זכות היוצרים בה, אחרת תסוכל צפייתו העסקית של המזמין, והזמנתו, שעבורה נתן תמורה, תתרוקן מתוכנה.

(2) סעיף 35(א) [לחק. זכות יוצרים](#) חל לא רק על פיתוחים אלא גם על צילומים ועל "דיוקן" (תמונה). השיקול וההיגיון שבפירושו לעניין הפיתוחים, כוחם עמם - גם לעניין הזמנת המקור, כלומר התשליל, של הצילום, ואילו כשהמדובר בדיוקן, אמנם מקורו לא נועד לייצור המוני של העתקים בתהליך מכאני או כימי או חר ובטכניקה כלשהי, אולם הוא מוזכר בסעיף הנ"ל בצוואת חדא עם "פיתוח" ו"צילום", משום שגם כאן יש כוונה משתמעת בהזמנה, כי מושא ההזמנה - כאן הדיוקן האישי או המשפחתי - לא יופץ ברבים על-ידי יוצרו, ובכך תימנע פגיעה באינטרס של המזמין (כאן - אינטרס לפרטיות).

(3) במקרה דנן אמנם שימש השלט כאב-טיפוס להכנת שלטים אחרים דומים לו, בגדלים ובמידות משתנים, אך מטבעו לא נועד לשמש אמצעי להפקה המונית של שעתוקים בהליכי ייצור כלשהם ובאמצעים טכניים כלשהם, ולפיכך לא היה הוא בגדר "פיתוח" וכן לא בגדר "צילום" או "דיוקן", ולפיכך דגם השלט איננו כלול בהוראת סעיף 35(א) [לחק. זכות יוצרים](#) בו היא איפוא של המערערים ולא של המשיבות.

ח. (1) על-מנת שעיצוב ייחשב כמידגם, הוא חייב להיות צמוד לחפץ שנועד למטרה אחרת בפני עצמו.

(2) במקרה דנן, העיצוב הגרפי הוא המטרה, למשוך את עיני העוברים ושבים. השלט נועד רק לשאת את הצויר הגרפי על גבו. הוא טפל לצויר ואין לו כל שימוש משל עצמו.

ט. (1) אין די בכלילת שלטים והתקני פרסומת ברשימה השלישית [לתקנות המדגמים](#) כדי להצדיק רישומם כמידגמים. לצורך כך צריך גם שיהיו מחוברים או מודבקים לחפץ אחר בר-שימוש עצמאי, ותתקיים בהם הגדרת "מדגם" שבפסקה [הפטנטים והמדגמים](#).

(2) אפילו ראוי שלט להירשם כמידגם, אין בכך כדי להוציאו מתחולת [חק. זכות יוצרים](#). הוא צריך בנוסף לכך לשמש או להיות מכון לשמש כמודל או כדוגמה המוכפלת בתהליך תעשייתי.

(3) במקרה דנן, השלט אינו עונה על אף אחד מהמקרים הנקובים בתקנה 72 של [תקנות המדגמים](#), אשר לפי סעיף 22(2) של [חק. זכות יוצרים](#) באה לקבוע את התנאים, שבהם ייחשב מידגם כמשמש כמודל או כדוגמה להכפלה על-פי תהליך תעשייתי.

י. (1) ככל שדלים המקוריות והמאמץ הרוחני שביצירה, כך נדרשת להפרת זכות היוצרים בה העתקה מדויקת יותר.

(2) במקרה דנן, המקוריות והמאמץ שבשלט הם צנועים ולעומת זאת ההעתק הוא כמעט מדויק, ובכך די להוות הפרה.

פסקי-דין של בית המשפט העליון שאוזכרו:

[1] [ע"א 136/71 מדינת ישראל נ' אחימן, פ"ד כו \(2\) 259](#).

[2] [ע"א 606/76 סי.בי. אל הנדסת פיברגלס בע"מ ואח' נ' לישק, פ"ד לא \(3\) 333](#).

פסקי-דין של בתי המשפט המחוזיים שאוזכרו:

[3] [ת"א \(ת"א\) 557/79 קוטליצקי ואח' נ' אלקלעי ואח' פ"מ תשמ"ב \(1\) 387](#).

[4] [ת"א \(ת"א\) 248/48 גפקו בע"מ נ' אהרונ, פ"מ יז \(ת\) 103](#).

פסקי-דין אנגליים שאוזכרו:

University of London Tutorial Press, Limited v. University of London Press, Limited [1916] Ch 2[5] . . 601

[6] Macmillan and Co., Limited v. Cooper (1923). . 186 T.L.R. 40

[7] Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.

[1964]. 273 W.L.R. 1 (H.L.).

[8] James Arnold & Co. Ltd. v. V&A Ltd [1980]

.. 397 R.P.C.

[9] Banco de Portugal v. Waterlow & Sons Ltd. (1931). L.T. 145

362 (C.A.).

[10] Charles Walker & Co. Ltd. v. The British Pickers Co. Ltd.

[1961]. . 57 R.P.C.

[11] Gambart v. Ball (1863). E.R. 143 463 (C.P.).

[12] Kenrick & Co. v. Lawrence & Co. (1890). Q.B. 25 .99

פסקי-דין אמריקניים שאוזכרו:

[13] Emerson v. Davies . 615 Fed. Cas (1845).

[14] Lithographic Co. v. Sarony . 53 U.S (1884).

--- סוף עמוד 344 ---

[15] Higgins v. Keufel . 428 U.S (1891).

[16] Alfred Bell & Co. v. Catala Fine Arts [1951]. 2 F. 2D . 99

[17]. 239 U.S . 188 Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.

[18] Gelles v. Widmer Company v. Milton Bradley Company - F

143 D2 (1963).

[19]. Mazer v. Stein [1954]. 460 S. Ct 74

[20] Drop Dead Co. v. S.C. Johnson [1963]. 87 D . 2F . 326 Son, Inc &

ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ה' בן-עתו) מיום 3.5.83. [בת"א 1454/79](#). הערעור נתקבל. י' צור - בשם המערערים;
א' לזין - בשם המשיבים.

פסק-דין

השופטת ש' נתניהו: 1. עניינו של ערעור זה בזכות יוצרים, אשר המערערים, גרפיקאים במקצועם, טוענים לה, בגין שלט פרסומת שעיצבו עבור המשיבות ואשר שימש כאב-טיפוס להכנת שלטים נוספים כדוגמתו, שהמערערים סיפקו למשיבות על-פי הזמנתן. בית המשפט קמא (כבוד השופטת ה' בן-עתו) קבע, כי השלט, שעוצב על-ידי המערערים, הינו "יצירה אמנותית מקורית", הראויה להגנה על-פי [חוק זכות יוצרים](#) האנגלי משנת 1911 (להלן - החוק), החל אצלנו מתוקף דבר המלך על חוק הקופירייט, 1911 (הטלתו על ארץ ישראל), 1924. על-אף זאת דחתה את תביעת המערערים, שעילתה בהפרת זכות היוצרים על-ידי המשיבות, מהטעם שהשלט מהווה "פיתוח" במובן [סעיף 5\(1\)\(א\)](#) של החוק, ועל-פי הוראת אותו סעיף המשיבות, שהשלט הוכן על-פי הזמנתן בתמורה, הן בעלות זכות היוצרים עליו, בהעדר הסכם המורה אחרת.

2. בתחילת הדיון בבית המשפט המחוזי הסכימו באי-כוח הצדדים על העובדות הבאות:

א. התובעים (המערערים שלפנינו) הם גרפיקאים, והנתבעות (המשיבות שלפנינו) הזמינו אצלם שלטים על-פי עיצוב של התובעים לשימוש מסחרי בעסקן.

ב. הנתבעות ביקשו, שהשלטים יכללו את שם הפירמה "ויטמן" ופרח, שעשו בו שימוש קודם לכן.

ג. התובעים עיצבו את השלטים המופיעים בנספח "א" [בהמ' 4290/79](#), ומוסכם, כי עיצוב השלט נעשה על-ידי התובעים תוך שימוש באלמנטים שצוינו לעיל, כבקשת הנתבעות.

--- סוף עמוד 345 ---

ד. התובעים הנהיגו פסים בפרסומת שעיצבו עבור לקוחות אחרים קודם לכן, והוסכם ביניהם לבין הנתבעות, שבשלטים יהיו גם פסים.

ה. בין הצדדים נעשה הסכם בעל-פה, בו נקבע מחיר עבור כל שלט שיוחקן על-ידי התובעים על-פי הדגם שעוצב על-ידיהם ושקיבל הסכמת הנתבעות, תוך התייעצות.

ו. על-פי ההסכם הזה יצרו התובעים שלטים עבור הנתבעות, והנתבעות שילמו עבורם מחיר, שהשתנה לפי גודל השלט, צורתו ומועד אספקתו - אך הכול על-פי אותו הדגם.

ז. בשלב מסוים זנחו הנתבעות את התובעים לאחר שינוי בעלות החברה הנתבעת 1 והחלו מזמינות שלטים כדוגמת אלה שבנספח "ב" להמרצה הנ"ל אצל הנתבעת 3 (הנתבעת 3 הייתה באותו זמן החברה החדשה, שאצלה הוזמנו השלטים, ובינתיים יצאה מהתמונה). למרות שינויים מסוימים שהוכנסו בשלטים נעשה שימוש על-ידי הנתבעות באופן כללי בדגם, שעוצב על-ידי התובעים.

ח. עוד לפני שפנו הנתבעות אל התובעים, עשתה החברת ויטמן שימוש באותיות בעלות אותו עיצוב המופיע בשלטים על אריות של גלידה. האריות הללו לא הוצגו לתובעים בעת הזמנת השלטים.

לא הוסכם במפורש, אך אין מחלוקת בין הצדדים, כי הגלידה באריות הללו נמכרה באופן חופשי בשוק.

אלה השאלות המתעוררות בערעור:

א. האם השלט הינו יצירה מקורית, הראויה להגנה על-פי החוק? ב. אם כן, האם היא "יצירה אמנותית" או "יצירה ספרותית"? חשיבות השאלה היא בכך, [סעיף 5\(1\)\(א\)](#) של החוק חל על יצירות אמנותיות

מסוימות אך אינו חל על יצירות ספרותיות; ג. אם "יצירה אמנותית" היא השלט, האם היא מהווה "פיתוח" במובן [סעיף 5\(א1\)](#)? ד. אם כן הדבר, האם הוסכם בין הצדדים במפורש או מכללא, שזכות היוצרים בו תהיה של המערערים? ה. האם השלט ראוי להירשם כמידע לפי [פקודת הפטנטים והמדגמים](#) (שהחליפה אצלנו את החוק האנגלי מ-1907)? שאז, כאמור [בסעיף 22](#) של [חוק זכות יוצרים](#), לא יחול עליו החוק, אלא אם הוא כלול בחריג לאותו סעיף:

אם אינו משמש כדוגמה המוכפלת בתהליך תעשייתי.
ו. אם השלט מוגן כיצירה אמנותית ואינו "פיתוח", האם הפרו המשיבות את זכות היוצרים של המערערים?

--- סוף עמוד 346 ---

3. השלט כיצירה מקורית.
הדרישה למקוריות נשמטה משום מה מהתרגום הרשמי העברי של חוקי ארץ ישראל, אך היא מופיעה [בסעיף 1](#) של הנוסח האנגלי של החוק, שהוא הנוסח הקובע: every original literary, dramatic, musical and artistic work... "ביטוי זה צריך שיהיה מקורי. אך הפירוש שניתן למושג "מקורי" הן בפסיקה האנגלית והן בפסיקה האמריקנית איננו המושג המקובל של חדשני, בר-חידוש כלשהו. אין היצירה צריכה להיות ביטוי של מחשבה או אמצאה מקורית. כל שנדרש הוא, שהיצירה לא תהיה מועתקת מיצירה אחרת, אלא שמקורה יהיה ביוצרה, במחברה.

פסק הדין האנגלי המנחה בעניין זה, שצוטט על-ידי הערכאה הראשונה, הוא: university of london press, limited v. University tutorial press, limited [5] (1916) 608-609: "original or novel But the act does not require that the expression must be in an" form, but that the work must not be copied from . " that it should originate from the w.a. e.p. skone james, on copyright& (,londonauthor- another work copinger41- 40, 37th ed., by e.p. skone james and others 12) (להלן קופינגר).

יחד עם זאת הלכה פסוקה היא באנגליה, כי היצירה צריכה להיות פרי מאמץ, כישרון והשקעה של המחבר, שיקנו לה אופי שונה משל החומרים שמהם עוצבה. פסק הדין המנחה הוא: macmillan and co., limited v. Cooper [6] (1923) בעקבות פסק הדין האמריקני [13] (1845) emerson v. Davies. ומיה מידתם של המאמץ, הכישרון וההשקעה הדרושים לכך? די לאלה במידה צנועה ביותר. פשטות היצירה בלבד לא תמנע הגנת זכות יוצרים, אלא אם היא קיצונית, כגון סתם קו ישר או עגול (ראה קופינגר, בעמ' 41-42, והאסמכתאות שם). די לבחון אם היצירה ראויה להגנה יש לראותה בכללותה, כשלמות אחת. אם, למרות השימוש שעשה המחבר בנושא קיים, השקיע ביצירה די מאמץ וכישרון עצמאיים משלו, שמקורם בו, תהיה היצירה מוגנת. ראה ladbroke (football) ltd. V. William hill (football) Ltd. (1964) [7]. כך המאמץ והכישרון הכרוכים בליקוט, בסידור ובעריכה של נושא קיים, יכולים להספיק (ראה גופינגר, בעמ' 46-47 וכך נפסק גם אצלנו ע"א 136/71 [1], בעמ' 261, שאוזכר בפסק-דינה של השופטת המלומדת).

דומה המצב בפסיקה האמריקנית. ראה m.b. nimmer, on copyright 9- 2- 5- 2 (1985-) (1884) [14], new york (1963) (להלן - נימר). מידת המקוריות הנדרשת שם היא צנועה. ראה, lithographic co. V. Sarony. 58at

--- סוף עמוד 347 ---

די בכך שהיצירה מציגה "a modicum of intellectual labour" though of minimal degree (נימר, בעמ' 48-1. וראה גם [15] (1891) Higgins v. Keufel). כל שינוי מעבודה קודמת,

שניתן להבחין בו, די בו אם השינוי הוא פרי מאמצו העצמאי של המחבר. כפי שנאמר בפסק הדין בענין, 103
alfred bell - Co & v. Catalda fine arts (1951) [16]at

actual copying. No Originality amounts to Little more than a prohibition of
"enough if it be his own matter how poor the author's addition, it is." enough if it be his own
2-12 - 2-11

קולעים דבריו של השופט holmes בעניין at 250, bleistsein v. Donaldson [17] (1903)
lithographig co:

singularity even Personality always contains something unique. It expresses its
in handwriting, and a very modest grade of art Has in it something irreducible
which is one man's alone. That . Something he may copyright unless there is a
restriction in the "words of the act" גם בארצות-הברית המאמץ והכישרון הכרוכים בליקוט, בסידור
ובעריכה של נושא קיים יכולים להספיק. ראה נימר, בעמ' 85-2 וכן gelles-widme [18] (1963)
company v. Milton bradley company:

expression, no matter how ... Almost any ingenuity in selection, combination or
"sufficient. 4. crude, humble or obvious, will be." השלט כיצירה הראויה להגנה.

כשם שהמושג "מקורי" במובן החוק אינו מבטא את התפיסה המקובלת והרגילה, לפיה מקורי הוא משהו
בר-חידוש, כך גם המושגים "יצירה אמנותית" ו"יצירה ספרותית" אינם מבטאים במובן החוק את התפיסה
המקובלת של יצירה בעלת רמה וערך. ביחס ל"יצירה ספרותית" נאמר בפסק הדין הנ"ל של [5]608,
university of london press, limited:

in print or writing, ... The words 'literary work' cover work which is expressed"
quality of style is high irrespective of the question whether the 'the word 'literary

---סוף עמוד 348---

Word 'literature' in political or electioneering literature and seems to be used in a
sense somewhat similar to the use of the . "refers to written or printed matter
מה שאנו היינו מכנים כ"חומר כתוב."

בהגדרת יצירה אמנותית בחוק זכות יוצרים האנגלי משנת 1956 (סעיף 3(1)(9)) נאמר במפורש, כי אין
חשיבות לערך האמנותי של היצירה-

"... Irrespective of artistic quality"

מלים אלה אינן מופיעות בהגדרת החוק מ-1911 החל אצלנו, אך נראה, שההגדרה החדשה לא באה
לחדש אלא רק לבטא את המצב המשפטי הקודם, כפי שהתגבש בפסיקה (ראה קופינגר, בעמ' 48-49),
ולפיו די ליצירה "אמנותית" שתהא תולדה ממידת מה של כישרון ועבודה של האמן. כפי שנאמר על-ידי
השופט הולמס (holmes) בפסק הדין הנ"ל בעניין [17]bleistsein, יהיה זה מסוכן, אם אנשים שמיומנותם
היא רק במשפט, ייקחו לעצמם את התפקיד להיות הפוסקים האחרונים בדבר ערכה האמנותי של תמונה.
וראה פסק הדין האמריקני בעניין at 468, [19]mazer v. Tein (1954):

"... Individual perception of the beautiful is too varied a power to permit a
narrow or rigid concept of art די בכך כדי שיצירה תיחשב כיצירה אמנותית או ספרותית, אם היא
עונה לטעמו של מיגזר מהציבור, ויהי זה בעל טעם מעודן אם המוני, היפי, אוואנגארדי או זעיר בורגני,
מבוגר או צעיר (ראה נימר, בעמ' 85-2).

אמנות שימושית גם היא בכלל אמנות, ויצירה שנועדה לתצרוכת מסחרית או לפרסומת גם היא זכאית
להגנה. ראה פסק הדין בעניין [19]mazer הנ"ל וכן נימר, בעמ' 118-2 - 120-2.

5. לאור אמות מבחן אלה אין ספק, כי צדקה השופטת המלומדת בהחלטתה, שהשלט הוא יצירה מקורית
הראויה להגנה. נכונה דעתה, כי אף-על-פי שהמערערים השתמשו בעיצובו בשם "ויטמן" (באותיות בעלות

אותו עיצוב שהמשיכות השתמשו בו כבר קודם לכן על אריזות הגלידה שלהן) ובסימן הפרח, שגם הוא היה בשימושן הקודם של המשיכות, ובפסים שהם, המערערים, השתמשו בהם קודם לכן, ובכל אחד מאלה לא היו חידוש ומקוריות, הרי די בכך שהם עמלו והשתמשו בכישורם המקצועי וחיברו את כל המרכיבים גם יחד ליצירה חדשה, משלהם, שמקורה בהם ושאינה העתק של יצירה אחרת. די, לדעתי, בכך כדי להגיע למסקנה, כי השלט הוא יצירה מקורית הראויה להגנה אף ללא השימוש בקנה המידה ה"גס", כביטוייה של השופטת המלומדת. המבחן המעשי הנזכר בפסיקה האמריקנית, כי אם נמצאה היצירה ראויה לחיקוי והועתקה, הרי שיש בה מידה מספקת של מקוריות (ראה פסק הדין [20] (1963) Son, inc & drop dead co. V. S.c.. (johnson)). מבחן זה אינו תמיד מבחן הולם, בייחוד כשמדובר בפרסומת, שהמניע להעתקה

--- סוף עמוד 349 ---

אינו דווקא בהיות היצירה ראויה לחיקוי. המניע יכול להיות בהתחרות בלתי הוגנת מצד זר או ברצון של המזמין להמשיך באותה צורת פרסומת של מוצריו, שכבר חדרה לתודעת הציבור.

6. האם השלט הוא "יצירה אמנותית או "יצירה ספרותית"? אלמלא ביקשו המערערים להינצל מהוראות [סעיף \(1\)5\(א\)](#), החל על פיתוח, צילום או תמונה (וכל אלה יכולים להיות "יצירה אמנותית" אך לא "יצירה ספרותית"), בוודאי לא היה איש מעלה בדעתו, ששלט פרסומת זה הוא יצירה ספרותית. אין בו כל כתב, להוציא המלה "ויטמן" (שהיא ממרכיבי שמה של המשיבה השנייה) בעברית ובאנגלית.

אכן, טקסט שבפרסומת יכול להיחשב כיצירה ספרותית, אם הוא יצירה הראויה להגנה, בעוד שהחלק הציורי או הגרפי של אותה פרסומת יכול להיחשב כיצירה אמנותית. כך המצב לגבי הדפסות ותוויות, כך לגבי מפות (ראה נימר, בעמ' 2-76, 2-114, 2-116, 2-118), וכך, כדוגמה שמביא באכוח המשיכות בסיכומיו, לגבי סיפורים מצוירים (cartoons), המכילים תמונה וטקסט. אך כדי שהיצירה תהיה ראויה להגנה כ"יצירה ספרותית", צריכה היא לתת ביטוי בכתב לרעיון כלשהו, דל ככל שיהיה, וצריכה היא למקוריות ולמידת מה של מאמץ וכישרון. כל אלה, כפי שקבעה השופטת המלומדת בצדק, חסרים בטקסט שבשלט. האותיות אינן יצירתו של המערער. השם עצמו הוא נתון קיים ומוכר. אין לא מקוריות, לא יצירתיות ולא ביטוי לרעיון כלשהו בטקסט כחומר כתוב. הוא מהווה חלק מהעיצוב גרפי, אך אין לו כל תפקיד עצמאי כחומר כתוב.

בא-כוח המערערים מנסה להיבנות מהגדרתה של "יצירה ספרותית" [בסעיף 35\(1\)](#) של החוק כ"כוללת מפות, תרשימים, תכניות, טבלאות וליקוטים". על סמך הגדרה זו הוחלט [בע"א 606/76](#) [2], בעמ' 335, כי אדריכל, המתכנן מבנה, יכול לתבוע זכות יוצרים לא רק עבור "מעשה אמן אדריכלי", כמוגדר [בסעיף 35\(1\)](#) שהגנתו משתרעת על האופי ועל העיצוב האמנותי, אלא גם כ"יצירה ספרותית", הכוללת על-פי הגדרתה בסעיף הנ"ל גם "תכניות", על סמך התוכן המחשבתי של התכנית עצמה. כך גם [בת"א \(ת"א\) 557/79](#) [3] הוחלט, שסדרת מעגלים חשמליים מודפסים לשימוש במערכת אזהרה הם "יצירה ספרותית" בהיותם "תרשימים ותכניות", הכלולים בהגדרתה של יצירה כזאת.

הכללתם בהגדרת "יצירה ספרותית" של מפות, תרשימים ותכניות נעדרת כל טקסט כתוב היא, כשלעצמה, אנומאליה, מה גם ש"שרטוט" כלול בהגדרתה של "יצירה אמנותית". בחוק האנגלי מ-1956 תוקן הדבר. כל אלה הושמטו מהגדרת "יצירה ספרותית" ונכללו בהגדרת "יצירה אמנותית" בדרך הגדרתו בסעיף 48 של המונח "drawing" ("שרטוט") הכלול שם בהגדרת "יצירה אמנותית" שהיא [diagram, map, chart or plan](#). ובשל ההגדרה הקיימת אצלנו אין אמנם מנוס מן הקביעה, שתכנית אדריכלית או סדרת מעגלים חשמליים מודפסים הם "יצירה ספרותית". אך אין כל מקום להרחיב אנומאליה זו מעבר למתחייב מן ההגדרה. מקובלת עלי לכן גם קביעתה של השופטת המלומדת, כי השלט "אינו יצירה ספרותית" אלא "יצירה אמנותית".

--- סוף עמוד 350 ---

7. האם השלט הוא "פיתוח"?

משנקבע, כי עניין לנו ב"יצירה אמנותית", מתעוררת השאלה, אם יצירה זו מהווה "פיתוח" ("engraving") במובן סעיף 5(א1), שאז, אלא אם הוסכם אחרת, המזמין בתמורה של הקלישאה או של המקור האחר הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים.

"פיתוחים" על-פי ההגדרה שבסעיף 35(1) של התרגום העברי "כוללים כתובות קעקע, פיתוחי-אבן, חיתוכי עץ, חיקוקים ושאר יצירות כיוצא בזה, פרט לצילומים" (ההדגשה שלי - ש' נ').

ובמקור האנגלי:

, ... 'Engravings' include etchings, lithographs, woodcuts"; prints, and other similar works, not being photographs.
 רחוק מלהיות משביע רצון. הביטוי "כתובת קעקע" אמור להיות תרגום של "etchings", שאינם כלל
 dictionary of current english- the etch- ראה פירוש הפועל כתבת. By engraving metal plate (1951,th ed., by e. Mcintosh 4,oxford)407 concise oxford
 ... Reproduce" etc. By means of acids or

"... Corrosion

- the new webster encyclopaedic dictionary of the english language (new york, edited by v.s. tatcher and a oxford, supra, at 395: "cut" (figures etc)." in lines on metal plate for printing engraving" (בתרגום העברי) "... From engraved plate engraving" (בתרגום העברי) ... Opy of picture etc- (webster, supra, at 289).

"חיקוקים" אמורים להיות תרגום של "print" שתרגומם הנכון הוא הדפסים. גם התרגום "העתקה מקורית אחרת" לצד קלישאה [בסעיף 5\(א1\)](#) אינו תרגום מדויק של המקור האנגלי "or other original-plate", שאינו "העתקה מקורית אחרת" אלא כל מקור אחר, שממנו או באמצעותו מופקים העתקים. בהגדרת "פיתוחים" בולט מכנה משותף כ- ejusdem generis, הוא יצירות המתקבלות כתוצאה מתהליך מכאני של שימוש בקלישאה ("plate") (שאנו היינו מתרגמים כ"גלופה") או באמצעי אחר. "plate" מוגדר [בסעיף 35\(1\)](#) ככולל:

---351 עמוד---

transfer, or negative , ... Stereotype or other plate, stone, block, mould, matrix"
used or intended to be used for printing or ."... Reproducing copies of any work
ובתרגום העברי:

"קלישאה" - כוללת כל סטריאוטיפ, או כל לוח אחר, אבן, תבנית, אימום, אם-דפוס, מעביר או נגטיבה המשמשים או מכוונים לשמש לטביעתן או לעשייתן של העתקות מכל יצירה. ...

עולה מכך, כי המדובר הוא בהעתקה, שיכפול או שיעתוק ("reproduce"ראה מ' שלי, מילון מונחי-משפט אנגלי-עברי (דביר מיקרושור, תשמ"ב); ר' אלקלעי, מילון אנגלי-עברי שלם (מסדה, 1970) וא' אבן-שושן המלון החדש (קרית-ספר) וראה **סעיף 134 לחוק העונשין**, תשל"ז-1977), הנעשים בתהליך המאפשר

הפקה המונית מתוך תבנית או לוח או מכשיר אחר מסוג כלשהו שהוכן לשם כך. אכן, ההגדרה [בסעיף 35\(1\)](#) איננה הגדרה ממצה, אך הקו המאפיין הזה עולה ממנה בבידור.

והנה, אין מחלוקת, שהשלטים, שהוזמנו אצל המערערים על-פי הדגם שעיצבו, לא הועתקו ולא שוכפלו ולא שועתקו בתהליך כלשהו מעין זה, אלא כל אחד מהם יוצר מחדש, באופן עצמאי ונפרד בגדלים שונים ובמידות שונות, אם כי על סמך העיצוב ועל-פי הדגם של השלט הראשון, ששימש כאבטיפוס.

השופת המלומדת סברה, כי לתהליך הייצור בו מועתקת היצירה אין כל חשיבות. לדעתה, די בכך שקיים דגם מקורי, שעל פיו מכינים דגמים אחרים זהים או כמעט זהים. בנמקה את דעתה זו ציינה, כי כתובת קעקע, למשל, לא ניתן לשכפל או להעתיק בתהליך של ייצור. אמנם כך, אבל כבר הראיתי לעיל, כי "כתובת קעקע" אינו תרגום נכון של "etchings", שהם תחריטים, ואלה נעשים בהליך מכאני, מתוך לוח שנחרט לצורך זה.

גם פסק הדין בעניין *James Arnold & Co. Ltd. V. Miaferm Ltd* [8], *others* (1980), שעליו בעיקר הסתמכה השופטת המלומדת, אינו תומך במסקנתה. שם היה מדובר במפורש בהליך מכאני של העתקת ציור מהנייר שעליו צויר אל פני פיסות בד, המיועדות לשמש כצעפים. ההעתיקה נעשתה בתהליך של חימום באמצעות סטריאו של גומי. הוחלט באותו פסק-דין, כי סעיף 4(3) של החוק מ-1956 (שהחליף את [סעיף 5\(1\)](#) של החוק מ-1911) חל לא רק על ההעתיקה, שנעשה על-פי אחד מהתהליכים העונים על הגדרת "פיתוח", אלא גם על הלוח או התבנית עצמם, המשמשים את ביצוע ההעתיקה (בעיה ו התעוררה שם, כי בחוק מ-1956, להבדיל מהחוק מ-1911, אין הגדרה של "קלישאה". נראה שלפי ההגדרה [בסעיף 35\(1\)](#) ולפי לשונו של [סעיף 5\(1\)\(א\)](#) אין הבעיה מתעוררת לפי החוק מ-1911). עוד הוחלט שם, שאף כי התהליך לא היה תהליך של פיתוח ("engraving") במובנו המדויק, הנעשה על-ידי חיתוך או חריטה במתכת,

--- סוף עמוד 352 ---

בעץ או בחומר אחר, הרי שאותו מכשיר גומי אף הוא בגדר "פיתוח". בהקשר לכך נאמרו שם, הדברים, שצוטטו על-ידי השופטת המלומדת ושאינם במלואם: Then it is said that to be an engraving must be made by the "engraving process, something which is made by cutting into Is in the terms of matal or wood or other material. I do not consider the matter is the 48so confined. The definition in section Which they achieve that form. It is also significant that it was particular works and does not direct attention to the process by Draughtsmen would think that they would otherwise be engravings thought necessary to exclude photographs expressly. Evidently the Original artistic craftsmanship, it is not to limit it to one or produced from engravings. The purpose Of mass production the picture or design is produced by a of the act is to protect Which is complex particular mode of expression rather than another. In these days used to mass produce a design as an engraving even series of artifacts and i would regard the final one in the line Though of itself may not on the one hand have sufficient Earlier artifacts, or on the other it is produced by moulding originality, Matter but my conclusion is that being mechanically and slavishly reproduced from the rubber stereotypes are rather than by cutting out. I have not found this at all an easy engravings for the puposes of the act". אין מקום להסיק מדברים אלה, שאין כל חשיבות לאופן הפקת ההעתיקים. המסקנה שניתן להסיק מפסק-דין זה היא, שאין חשיבות באיזו טכניקה מתבצע ההליך, ואין לדקדק בדרישה, שהתהליך ייעשה בדרך חריטה או חיתוך דווקא, כמשתמע מן המונחים "engravings", "lithograph", "etchings", ו-"woodcuts", שהם כולם תהליכי חריטה או חיתוך בחומרים שונים (כעולה מהגדרתם במילונים *oxford* - *webster*). די בכך, שיהיה זה תהליך שבאמצעותו מופק שעתוק המוני בכל טכניקה שהיא, ולא דווקא על-ידי שקעים בקלישאה הנוצרים בדרך חריטה או חיתוך. די בטכניקה של תבליט (relief), של תשליל וכן אמצעים שונים אחרים, ככל שחידושי הטכניקה המודרנית המתקדמת מאפשרים. דבר זה מתיישב עם הגדרתה של הקלישאה המצוטטת לעיל. אין מקומה באותו פסק-דין, המצדיק את המסקנה, כי אין כל חשיבות לאופן בו נעשתה ההעתיקה. אם אכן כך, הרי גם ציור יד, המהווה חיקוי מדויק או העתק של ציור אחר, אף הוא ייחשב כ"פיתוח". פירוש כזה

--- סוף עמוד 353 ---

יביא לידי אבסורד, שכל ציור וכל פסל וכל יצירה אמנותית, שאפשר לעשות מהם חיקוי יד, ייחשבו ל"פיתוחים". המבחן, שמציע בא-כוח המשיבות בתשובה לכך, הוא, שיצירה, שהאמן יעד אותה מראש להיות ציור, הרי היא ציור, ויצירה, שהועיד אותה מראש להיות אב-טיפוס או דגם להכנת אחרים כמותה, הרי היא "פיתוח". הבחנה כזו, לפיה אותה יצירה תוכל להיות "פיתוח" ותוכל שלא להיות "פיתוח", הכול בהתאם לכוונה הסובייקטיבית של יוצרה, אין בה כל טעם והיגיון.

גם בפסק הדין בת"א (ת"א) 248/48[4], שעליו הסתמכה השופטת המלומדת, מדובר בתהליך מכאני של ייצור אותיות מתכת לשימוש בבתי-דפוס מתוך צורה או תבנית. כך גם עולה מהאמרה בפסק הדין, *banco [9]363at de portugal (1931) v. Waterlow . Sons ltd*, שאף הוא אוזכר בפסק הדין, ושבו מדובר היה בתהליך מכאני של הדפסת שטרי כסף. וכך גם בפסק-

דין נוסף, שאוזכר על-ידי השופטת המלומדת, בעניין *charles walker [10] (1961) Co. Ltd v. The british picker co. Ltd & pate* [\[בסעיף 5\(1\)\(א\)\]](#), ואשר תרגומו בנוסח העברי הוא "תבנית אימום". גם כאן מדובר איפוא בתהליך שיעתוק מכאני מתוך תבנית. בפסק-דין זה יכול להיות לנו עניין בשאלה אחרת, שכבר נדונה לעיל, שהתווית (אשר ציורה מופיע באותו פסק-דין), שהכילה גם ציור גראפי וגם מלים (רבות מהמלה האחת "ויטמן" שבשלט שלנו), הוכרה שם כ"יצירה אמנותית", ואיש לא העלה את הטענה, שהיא מהווה "יצירה ספרותית". הוראת [\[בסעיף 5\(1\)\(א\)\]](#) חלה גם על צילומים. גם אלה מועתקים באופן מכאני מתשליל. אלמלא דובר בנפרד ב"צילום" בסעיף זה, אין ספק, שניתן היה לכלול אותו בהגדרת "פיתוח".

לדעתי, יש להגביל את פירושם של "פיתוחים" [\[בסעיף 5\(1\)\(א\)\]](#) לתהליכי ייצור, המאפשרים שיעתוק המוני, תהליכים מכאניים, כימיים או אחרים, ותהא הטכניקה לכך אשר תהיה. השווה: *gambat v. Ball 468*, [\[בסעיף 5\(1\)\]](#), כפי שניתן להבינה על רקע הרעיון הכללי והמטרה של [חוק זכות יוצרים](#).

חוקי זכות היוצרים למיניהם נעדו להגן על מי שיצר יצירה מקורית מפני מעתיקים מתחרים. באנגליה הכיר המשפט המקובל כבר מתחילת המאה החמש-עשרה, כי יש להעניק זכות בלעדית, לתקופה מוגדרת, ליוצר המקורי לשעתק ולמכור העתקים מיצירותיו, היא זכות היוצרים, שאם יורשו אחרים לעשות כן, יגזלו את פרי כישורונתיו ומאמציו (ראה דו"ח ועדת ויטפורד 1977 פקודה 6732 סעיפים 14, 23).

ועדת ויטפורד המליצה על חקוקה של הוראה מפורשת, כי ליוצר נתונה זכות היוצרים ביצירותיו, בכפוף רק להוראה חוזית, או, בהעדרה, להוראה סטטוטורית. הוראה סטטוטורית כזו, כחריג לזכות היוצרים הכללית, כלולה [\[בסעיף 5\(1\)\]](#) מ-1911 ובסעיף 4(3) מ-1956. אלה ההוראות הסטטוטוריות המצויות.

--- סוף עמוד 354 ---

בשאלה מה ההוראה הסטטוטורית הרצויה דנו גם ועדת גרגורי מ-1952 (פקודה 8662) גם ועדת ויטפורד. באחרונה לא הושגה תמימות דעים בשאלה זו. יש הסוברים, כי מן הראוי להקנות למזמין כל יצירה מוגנת את זכות היוצרים הראשונה. לעומתם יש הסוברים, כי טוב מעמדו של המזמין ממעמדו של היוצר להבטיח את זכויותיו בהסכם מפורש, וכי בהעדר תניה חוזית אין מקום להעניק לו זכויות יוצרים ביצירה כלשהי. גישה שלישית - בתווך בין שני הקצוות - היא, כי מן הראוי להקנות למזמין של כל יצירה זכות יוצרים מוגבלת לשימוש ביצירה רק למטרה שלשמה הוזמנה. המלצת הוועדה, ברוב דעות, הייתה, כי בהעדר הסכם אחר זכות היוצרים בכל יצירה תהיה ליוצר, בכפוף לשתי הגבלות. האחת - למזמין תהיה רשות בלעדית (*exclusive licence*) מוגבלת למטרות שהיו בכוונת הצדדים בעת ההזמנה, והאחרת - ליוצר תהיה הזכות למנוע ניצול למטרות אחרות, שנגדן רשאי הוא לעורר התנגדות סבירה. המלצה זו לא אומצה. ראה מסמך מייצג (*consultative document*), שהוגש לפרלמנט על-ידי מזכיר המדינה למסחר מיולי

1981(פקודה 3802), בו מועלות הסתייגויות הן מדעת המיעוט והן מדעת הרוב של ועדת ויטפורד והצעה להשאיר את ההוראה שבסעיף 4(3) של החוק מ-1956 ללא שינוי.

לדעתי, הרעיון שבהוראה זו והוראת [סעיף 5\(1\)](#) מ-1911 הברורה ממנה, כעילה מפסק הדין הנ"ל בענין james arnold . Co. Ltd & [8] (ראה לעיל), הוא מתן תוכן עסקי להזמנה. עניינו של מזמין בתמורה של גלופה, המיועדת, מעצם טבעה, להפקה המונית של העתקים, הוא בהעתקים. הגלופה עצמה נשארת, בדרך כלל, בידי היוצר. אם תישאר גם זכות היוצרים בידו, מה פעל המזמין? צפייתו העסקית תסוכל, והזמנתו, שעבורה נתן תמורה, תתרוקן מתוכנה. אישור לדעתי מוצאת אני באמור בסעיף 11 של המסמך המייעץ הנ"ל.

[סעיף 5\(1\)\(א\)](#) חל לא רק על פיתוחים אלא גם על צילומים ועל

"תמונה". השיקול וההיגיון שבפירושו לעניין הפיתוחים כוחם עמם גם

לעניין הזמנת המקור, כלומר התשליל, של צילום.

גדר הספק היחיד שלי התעורר בשל הכללתה של "תמונה", שתרגומה הנכון הוא "דיוקן", לצד פיתוח וצילום. לכל הדעות, מקורו של דיוקן לא נועד לייצור המוני של העתקים בתהליך מכאני או כימי או אחר ובטכניקה כלשהי. מה הטעם בצירוף המוזר לכאורה של דיוקן לפיתוח או לצילום? את התשובה מצאתי במסמך המייעץ הנ"ל בסעיף 11 וכן בסעיף 561 של דו"ח ועדת ויטפורד: הטעם הוא בנימוקי פרטיות אישית של המזמין. המזמין דיוקן אישי או משפחתי מטבע הדברים אינו רוצה שהוא יופץ ברבים, ויש לראות כוונה משתמעת בהזמנה, כי הדבר לא ייעשה. כך הדבר גם בצילומים מסוימים, ו"צילום" משתלב לכן גם עם הרעיון שמאחורי הפיתוחים וגם עם זה שמאחורי הדיוקן.

אך כל השיקולים הללו, המצויים בהזמנתם של גלופה, צילום או דיוקן, אינם מצויים בהזמנתו של השלט הנדון כאן, שאמנם שימש כאב-טיפוס להכנתם של שלטים אחרים

--- סוף עמוד 355 ---

דומים לו, בגדלים ובמידות משתנים, אך מטבעו לא נועד לשמש אמצעי להפקה המונית של שעותקים בתהליכי ייצור כלשהם ובאמצעים טכניים כלשהם.

בארצות-הברית נמצא הסדר אחר להקניית הבעלות בעבודות היוצרים למזמין היצירה, ולא נוכל ללמוד משם במישרין. החוק מ-1909 הקנה זכות זו, בתנאים ובסייגים מסוימים, למזמין של כל יצירה ללא הגבלה. החוק מ-1978 הגביל זאת לסוגי יצירות מסוימים ומוגדרים ברשימה סגורה, תוך תנאים וסייגים אחרים.

לא מצאתי כל טעם בטענה החלוטית של בא-כוח המשיבות, שאם השלט אינו מהווה "פיתוח", כי אז הרי הוא "צילום" או "תמונה".

דעתי, העולה מן המקובץ, היא, כי דגם השלט איננו כלול בהוראת [סעיף 5\(1\)\(א\)](#). לפיכך זכות היוצרים היא של המערערים ולא של המשיבות.

8. מסקנתי, כי אין מדובר ב"פיתוחים", מייתרת את הצורך לדון בשאלה ד' שהצבתי לעיל, האם הוסכם בין הצדדים במפורש או מכללא שזכות היוצרים תהיה של המערערים.

9. האם ראוי השלט להירשם כמידגם.

אם כך הדבר, כי אז תחולנה הוראות [סעיף 22\(1\)](#) של החוק על החרג שבו. על שאלה זו השיבה השופטת המלומדת בשלילה, בנימוק שעל-מנת שיעיזב ייחשב כמידגם הוא חייב להיות צמוד לחפץ שנועד למטרה אחרת בפני עצמו. על זאת אין חולק, וראה קופינג'ר, בעמ' 84-85, וכן ת"א (ת"א) 557/79 [3] הנ"ל. המחלוקת היא בשאלה, אם השלט, כפי שקבעה השופטת המלומדת, "אינו שמיש כשלעצמו ואין בו אלא... חזותו החיצונית".

טענת בא-כוח המשיבות היא, כי לא השלט ככלל עומד למבחן אם ראוי הוא להירשם כמידגם אלא המרכיבים המוטבעים עליו (הפרח, המלה "ויטמן", גביע הגלידה, והפסים) הם הראויים להירשם. אם ירדתי לסוף כוונתו, הרי היא, כי מרכיבים אלה הם המידגם המחובר אל הגוף או החפץ האחר, הוא השלט. על-פי הטענה, יש לשלט שימוש עצמאי משלו בנפרד מאותם מרכיבים, דוגמת נייר הקיר הנושא עליו ציורים,

שקופינג'ר מדבר בם (שם). אך המשל אינו דומה לנמשל. הציור נועד לקשט את הנייר, אך לנייר יש שימוש עצמאי משלו. הוא נועד להדבקה או לציפוי של הקיר, ואילו כאן העיצוב הגרפי לא נועד לצפות את השלט. העיצוב עצמו הוא המטרה, למשוך את עיני העוברים והשבים. השלט נועד רק לשאת את הציור הגרפי על גבו. הוא טפל לציור ואין לו כל שימוש משל עצמו. קולעת יותר לענייננו הדוגמה שנותן קופינג'ר בהמשך אותו קטע, שם: "It is submitted that a drawing or painting intended to be reproduced upon a christmas card falls under the copyright act regard to an advertisement".

---סוף עמוד 356---

Cover the boarding upon which it is to be posted, but to produce poster for the object of a person in designing a poster in not to "by-a picture which will attract the passer (סוג 20 תת סוג 3: "... סמנים, שלטים והתקני פרסומת") אין בו כדי לתמוך בטענת המשיבות. לא די באלה להצדיק רישומם כמידגמים, אלא אם מתקיימת בהם גם הדרשה הנוספת, שיהיו מחוברים או מודבקים לחפץ אחר בר-שימוש עצמאי, ואלא אם מתקיימת בהם הגדרת "מדגם" שבפקודת הפטנטים והמדגמים. חפצים אלה יכולים מטבעם גם להיות מחוברים לחפץ אחר בר-שימוש עצמאי, ורק אז יהיו ראויים להירשם כמדגמים.

אך אפילו ראוי השלט להירשם כמידגם, אין די בכך כדי להוציאו מתחולת [חוק זכות יוצרים](#). הוא צריך בנוסף לכך לשמש או להיות מכוון לשמש כמודל או כדוגמה המוכפלת בתהליך תעשייתי. בא-כוח המשיבות טוען, שהשלט עונה על דרישה זו. אך לכך אין כל ראיה לפנינו. העובדות היחידות הן אל שפורטו בהסכמת הצדדים. מלבדן לא הוכח מאומה, ומהן לא עולה כלל, שהשלט שימש או נועד לשמש להכפלה בתהליך תעשייתי. כמשתמע מסיכומי באי-כוח שני הצדדים, ההפך הוא הנכון.

יתרה מזאת, השלט אינו עונה על אף לא אחד מהמקרים הנקובים [בתקנה 72](#) של [תקנות המדגמים](#), אשר לפי [סעיף 22\(2\)](#) של [חוק זכות יוצרים](#) באה לקבוע את התנאים, שבהם ייחשב מדגם כמשמש כמודל או כדוגמה להכפלה עלפי תהליך תעשייתי.

המסקנה היא, ש[חוק זכות היוצרים](#) אכן חל על השלט.

10. האם הופרה זכות היוצרים של המערערים.

שאלה זו, שבא-כוח המשיבות עורר בסיכומיו, לא נדונה בבית המשפט קמא. רק אגב הדיון בשאלת המקוריות במרכיבי השלט והחלת ה"מבחן הגס" של היותו ראוי לחיקוי (שבו דובר לעיל), ציינה השופטת המלומדת, כי המשיבות, בהיותן ערות לכך שאולי הן מפרות זכות יוצרים, טרחו להכניס מספר שינויים בשלטים שהזמינו במקום אחר. שינויים אלה, כפי שקבעה, "הם כה מזעריים עד כי הם מזכירים חידה לילדים בה הם מתבקשים למצוא את ההבדלים בין שני ציורים הנראים לכאורה זהים לחלוטין". אחרי מימצא זה לא אבוא להרהר, ודי בו לקביעה, שזכות היוצרים של המערערים הופרה על ידי המשיבות.

טענת בא-כוח המשיבות היא, שכאשר המקוריות והמאמץ הרוחני שביצירה הם כמעט אפסיים, כמו, לדעתו, בשלט זה, אין הפרה אלא בהעתק מדויק. הוא מפנה לאמור בספרו של patents: w.r. cornish, 351-352 intellectual property (1981, london) copyright, trade marks and allied rights [12] (1890) Co.&.kenrick . V. Lawrence& co.

--- סוף עמוד 357 ---

אינני סבורה, כי תיאור זה מתקיים בשלט. אולי יש מקום למשוואה כללית של יחס הפוך, כי ככל שדלים המקוריות והמאמץ הרוחני שביצירה, כך נדרשת להפרת זכות היוצרים בה העתקה מדויקת יותר. על-פי משוואה זאת ניתן לומר, כי המקוריות והמאמץ שבשלט הם צנועים, ולעומת זאת ההעתק הוא כמעט מדויק. בכך די להפרה.

הייתי מקבלת את הערעור ומחזירה את הדיון לבית המשפט המחוזי, עלמנת שידון בסעדם המבוקשים על-ידי המערערים. המשיבות, הדדית, תשלמנה למערערים את יציאותיהם וכן שכר טרחת עו"ד כאן ולמטה בסך של 1,500,000 שקל צמוד ונושא ריבית מהיום.
הנשיא מ' שמגר: אני מסכים.

השופט א' גולדברג: אני מסכים.

הוחלט כאמור בפסק-דינה של השופטת נתניהו. ניתן היום, כ"ב באלול תשמ"ה (8.9.85).

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן.](#)

עא 360/83 סטרוסקי בע"מ נ' גלידת ויטמן בע"מ

-

-

פ"ד מ(3) 340,

www.nevo.co.il

-